

1500549-11.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... acusado Matheus quanto ao crime de tráfico de drogas, e a absolvição do corréu Kayky por este delito. Requereu, também, a absolvição de ambos os réus quanto ao crime de associação para o tráfico. Quanto ao acusado Matheus, formulou pedidos relativos à dosimetria da pena e à fixação do regime prisional.

A Defesa do acusado Kayky, em memoriais, pugnou pela absolvição do réu, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Criminal

Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1500549-11.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500549-11.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAYKY SOUZA SILVA ALVES e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

MATHEUS SILVA GALDINO PEREIRA e KAYKY SOUZA SILVA ALVES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, e no artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06 e ambos c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, em ocasião de calamidade pública, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta, ainda, que, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na exordial, o acusado Matheus trazia consigo, para fins de tráfico, 41 porções de cocaína, 30 pedras de crack e 23 porções de maconha, substâncias que causam dependência física e psíquica, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que o acusado Kayky auxiliava Matheus na venda dos entorpecentes. Foram apreendidas, ainda, com Matheus a quantia de R\$253,80 e com Kayky a quantia de R\$15,00 e um telefone celular.

Os réus foram notificados e apresentaram defesas preliminares. A denúncia foi recebida e os réus foram citados.

Durante a audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia e as testemunhas arroladas pela Defesa do acusado Kayky. Ao final, foram os réus interrogados.

Ao final da audiência, foi deferido o pedido feito pela Defesa do acusado Kayky para a juntada de mídia com mensagem gravada, que não veio aos autos.

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se em memoriais.

O Ministério Público pediu a procedência parcial da ação, para condenação do acusado Matheus quanto ao crime de tráfico de drogas, e a absolvição do corréu Kayky por este delito. Requereu, também, a absolvição de ambos os réus quanto ao crime de associação para o tráfico. Quanto ao acusado Matheus, formulou pedidos relativos à dosimetria da pena e à fixação do regime prisional.

A Defesa do acusado Kayky, em memoriais, pugnou pela absolvição do réu, por falta de provas quanto a ambos os crimes. Requereu, por fim, a devolução da quantia em dinheiro e do celular apreendidos com o acusado, pleiteando, outrossim, a revogação de sua prisão preventiva.

A Defesa do acusado Matheus, por sua vez, pugnou por sua absolvição quanto a ambos os delitos, por falta de provas. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base em seu mínimo legal, bem como o afastamento da circunstância agravante relativa à calamidade pública e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Pediu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e requereu a fixação do regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes ficou comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelo auto de constatação, pelo laudo de exame químico-toxicológico, bem como pela prova oral produzida em Juízo.

Também não restam dúvidas quanto à autoria do delito de tráfico de drogas, porém apenas quanto ao acusado Matheus.

Interrogados em Juízo, os acusados negaram a prática dos crimes descritos na denúncia.

Kayky contou que foi à casa de sua sogra com sua esposa para buscar seu filho, mas, no trajeto, ao se aproximar de uma "biqueira", pediu que sua esposa seguisse sozinha, pois iria comprar maconha e cigarro. Alegou que, ao chegar em uma esquina, ouviu gritos de que a polícia estava se aproximando e continuou caminhando. Disse que os policiais abordaram Matheus e depois um policial foi ao seu encalço, abordando-o e levando-o ao local onde estava Matheus. Contou que, antes de Matheus ser abordado, havia visto um indivíduo passando pelo local de bicicleta. Disse que, indagado pelos policiais se estaria na "biqueira", se iria assumir algo e se teria dinheiro, declarou a eles que nada tinha a falar, pois somente iria comprar maconha e cigarro. Contou que a quantia de R\$15,00 apreendida consigo era fruto de seu trabalho. Disse que costumava ir àquele local para comprar drogas, mas não conhecia Matheus e nunca o havia visto vendendo entorpecentes naquele ponto. Alegou que não viu Matheus sendo abordado, pois estava de costas e a uma distância de 25 metros, e não viu as drogas que foram apreendidas, tendo sido a bolsa contendo entorpecentes jogada por um policial dentro da viatura quando lá já estava detido com Matheus.

Disse que havia pessoas passando pelo local dos fatos, mas ninguém mais foi abordado. Contou que se encontra detido no mesmo local em que Matheus, mas não conversam sobre os fatos. Disse que, antes de ser detido, trabalhava com seu tio realizando manutenção de pranchas, recebendo R\$600,00 por semana. Declarou que faz uso somente de maconha, desde os 15 anos, consumindo dois "baseados" por dia.

Matheus disse que tinha uma dívida pendente e, sem ter conseguido dinheiro para pagá-la, decidiu vender sua bicicleta e a ofereceu em uma "biqueira". Contou que o indivíduo que estava na "biqueira" lhe entregou R\$250,00 pela bicicleta. Disse que também pediu a esse indivíduo três porções de maconha e quando ele iria lhe entregar as drogas, subitamente montou em sua bicicleta e evadiu-se. Alegou que, ao olhar para o lado, os policiais já estavam no local e o abordaram. Disse ter negado a prática do crime, mas os policiais não acreditaram em sua versão. Contou que não conhecia o indivíduo que comprou sua bicicleta e não soube se ele havia visto a

viatura anteriormente, somente tendo visto que ele montou rapidamente em sua bicicleta e saiu do local. Alegou que quando esse indivíduo montou na bicicleta, a sacola com drogas que ele estava portando caiu de sua mão. Disse que, ao ser abordado, dois policiais ficaram consigo e outros três realizaram busca no local, retornando com Kayky. Contou que não conhecia Kayky anteriormente aos fatos e não soube dizer se algo foi encontrado com ele. Alegou que as drogas já haviam sido apreendidas quando os policiais se aproximaram com Kayky. Declarou que não estava trabalhando à época dos fatos e não conhecia os policiais que o abordaram.

Contudo, a negativa do acusado Matheus e a versão por ele apresentada, além de não serem críveis, restaram isoladas no contexto probatório.

A testemunha policial militar Alexandre Pachioni, ouvida sob o crivo do contraditório, relatou que, durante patrulhamento, viu os réus parados em uma esquina. Declarou que, ao notarem a presença da viatura, o acusado Matheus dispensou naquele mesmo local, no chão, a bolsa de cor preta que estava segurando e ambos saíram andando rapidamente, o que despertou a atenção da equipe policial. Disse que alguns metros à frente foi realizada a abordagem de ambos e, em busca pessoal, com o acusado Matheus foi encontrado o valor de R\$253,80 e com o corréu Kayky foi localizada a quantia de R\$15,00. Recuperada a bolsa que havia sido dispensada pelo acusado Matheus, nela foi encontrada 23 porções de maconha, 30 pedras de crack e 41 pinos de cocaína. Narrou que o acusado Matheus acabou por admitir, informalmente, que estava realizando o tráfico, e por esta atividade receberia R\$100,00, dizendo, ainda, que costumava dividir o horário em que praticava o crime com o corréu Kayky. Narrou que o corréu Kayky, ao ser indagado sobre os fatos, permaneceu a maior parte do tempo em silêncio e nem mesmo declarou que estaria no local para comprar drogas. Declarou que nenhum outro elemento foi apurado que indicasse o auxílio mútuo para a prática do tráfico de drogas, além da confissão informal do acusado Matheus, e também não foi apurado se ambos já estavam associados anteriormente para a prática do tráfico de drogas. Disse que não havia nenhuma outra pessoa no local que tenha presenciado a abordagem e a apreensão das drogas e consignou que nenhuma outra pessoa empreendeu fuga no momento da abordagem. Não conhecia os réus anteriormente aos fatos. Narrou que o local dos fatos é conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes e consignou que, desde o primeiro momento em que avistou os acusados, viu a bolsa preta nas mãos de Matheus. Esclareceu que estava muito próximo dos acusados, a pouco mais de um metro, quando viu o acusado Matheus dispensando a bolsa no chão. Disse que ambos saíram do local andando, mas logo foram abordados. Declarou que estava anoitecendo quando os fatos ocorreram, porém foi possível visualizar a bolsa na mão do corréu Matheus, estando o acusado Kayky ao lado dele. Disse que não visualizou a efetiva venda de drogas antes da abordagem.

A testemunha policial militar Jonathan da Silva Fernandes, ouvida em Juízo, narrou que realizava patrulhamento quando avistou os acusados e estes saíram do local repentinamente ao verem a viatura. Asseverou ter visto o corréu Matheus dispensando no chão, próximo à calçada no local em que ele foi visto, a bolsa de cor preta, pequena, que ele estava segurando. Relatou que ambos foram, então, abordados. Disse que somente os acusados estavam no local dos fatos e não havia outras pessoas próximas que tenham presenciado a abordagem. Declarou que o local já é conhecido como ponto de tráfico de drogas, mas esclareceu que a abordagem foi motivada pela conduta do corréu Matheus em dispensar no chão a bolsa que segurava ao ver a viatura. Narrou que o acusado Matheus admitiu, informalmente, que estava realizando o tráfico de drogas no local e que o corréu Kayky iria "rendê-lo", pois faziam a troca de "serviço" do tráfico. Não conhecia os réus anteriormente aos fatos. Relatou que foram apreendidas 23 unidades de maconha, 30 pedras de crack e 41 eppendorfs contendo cocaína. Disse que com o acusado Matheus foi localizada a quantia de R\$253,00 e alguns centavos e com Kayky foi apreendida a quantia de R\$15,00 e um aparelho telefônico. Declarou que estava próximo aos acusados no momento em que os viu, em distância aproximada de cinco metros, e logo os abordou. Relatou que estava anoitecendo quando os fatos ocorreram e consignou que foi possível ver o acusado Matheus com a bolsa, bem como vê-lo dispensando-a no chão. As testemunhas arroladas pela Defesa do acusado Kayky não presenciaram os fatos.

Tatiana Ferreira do Nascimento disse conhecer Kayky desde a infância e declarou desconhecer qualquer envolvimento dele com drogas. Contou que o acusado Kayky trabalhava e nada sabia que o desabonasse.

Marcelo de Souza Mota, disse ser tio do acusado Kayky e foi ouvido como informante do Juízo. Contou que Kayky trabalhava consigo fazendo manutenção de pranchas e disse desconhecer o envolvimento dele com drogas. Não conhecia o corréu Matheus e disse não saber quem eram os amigos de Kayky após ele sair do trabalho. Disse que Kayky saiu do trabalho às 18 horas na data dos fatos.

Não há dúvidas, portando, sobre a conduta criminosa do acusado Matheus, quanto ao delito de tráfico de drogas a ele imputado, diante das provas produzidas.

Ressalta-se a palavra dos policiais, que de maneira segura, uniforme e convincente, descreveram com detalhes como ocorreu a abordagem dos acusados, bem como de que forma ocorreu a localização e a apreensão das drogas que viram em poder do corréu Matheus.

Não há nos autos qualquer elemento idôneo hábil a retirar a credibilidade dos testemunhos policiais.

Como já se decidiu "é bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos de policiais, tanto que sequer os isenta do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, se vierem sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre é conferir a tais declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, conferindo-lhes, ou não, segundo seu livre poder de convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética, de veracidade a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente de segurança para, ao depois, quando ele fosse convocado a prestar contas de sua atuação, negar-lhe valor, aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não diz a verdade" (Apelação criminal nº 112.195-3/1, Santos, Rel. Des. Canguçu de Almeida, em 07/10/1991, 2ª Câmara Criminal).

Aliás, mostra-se "imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que o depoimento de policiais responsáveis pela segurança pública, não podem ser desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem função de salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento" (TJSP - AP - Rel. Walter Guilherme - j. 10.03.98 - JTJ 214/284).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de manifestar-se favoravelmente à validade desses depoimentos. A propósito, registro: "Tóxicos - Tráfico - Prova testemunhal: Depoimento de policiais. A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Precedente" (STF - 2a T.- HC nº 74.522-9/AC - Rel. Min. Maurício Correa - DJU 13/12/96, pág. 50.167).

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais -Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1a Turma - HC nº 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

No mesmo sentido:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO INCORRETO. MENORIDADE RELATIVA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO À MÍNGUA DE PEDIDO NO RECURSO MINISTERIAL. REGIME FECHADO. PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada em poder do réu.

2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10).

Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP – Rel. Min. Moura Ribeiro – j. 27.05.14; RHC 45.173/SP – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 26.05.14 e HC 109.105/SP – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – j. 23.02.10).

3. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminoso. Precedentes do STF (AP 470/MG – Pleno – Voto Min. Cezar Peluso – j. 28.08.12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG – Pleno – Voto Min. Luiz Fux – j. 28.08.12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 838/842).

4. Dosimetria da pena estabelecida de modo incorreto. Menoridade relativa. Correção de ofício.

5. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminoso. Precedentes do STF (HC 121.057/SP – Rel. Min. Luiz Fux – j. 25.02.14 – DJU 18.03.14; HC 118.380/SP – Rel. Min. Teori Zavascki – j. 04.02.14 – DJU 14.02.14; HC 116.541/ES – Rel. Min. Gilmar Mendes – j. 21.05.2013 – DJE 06.06.13; HC 109.236/SP – Rel. Min. Cármen Lúcia – j. 13.12.11 – DJU 14.23.12). Manutenção à míngua de pedido no recurso Ministerial.

6. O regime inicial de cumprimento de pena para os crimes de tráfico de drogas será

o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.

7. Provimento do recurso do Ministério Público e correção, "ex officio", da dosimetria da pena." (Ap. nº 3003382-41.2013.8.26.0471; Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Porto Feliz; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 01/06/2016; Data de registro: 07/06/2016) (grifo nosso)

"Tráfico de entorpecentes - Agente que mantém em depósito e guarda substância estupefaciente - Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda - Caracterização

Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "manter em depósito" e de "guardar".

Tráfico de entorpecentes - Agente que vende substância estupefaciente a policial pensando tratar-se de consumidor - Apreensão que quantidade expressiva de entorpecente por ele guardado - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Alegação do agente no sentido de ser apenas usuário incompatível com o conjunto probatório e com a quantidade de entorpecente apreendida

Realiza o tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 o agente que vende substância estupefaciente a policial, pensando tratar-se de consumidor. Ainda que assim não fosse, o próprio estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente não é necessário para caracterizar o tráfico, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "manter em depósito" e "guardar". A ulterior alegação de que a substância ilícita se destinaria apenas ao uso próprio não se coaduna com a dinâmica de sua apreensão, devendo ser afastada.

No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da Pena - Tráfico de Entorpecentes - Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos nos art. 59 do CP em razão da quantidade e a variedade do entorpecente apreendido - Admissibilidade

Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06) é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na variedade e qualidade do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.

Cálculo da Pena - Tráfico de entorpecentes - Desnecessidade de comprovação de nexos causal entre a conduta do acusado e a circunstância da apreensão ter ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino - Causa de aumento de pena (art. 40, III, da Lei nº 11.343/06) de natureza objetiva - Reconhecimento

Imperioso o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 sempre que for constatado que o tráfico de drogas estava sendo praticado nas imediações de estabelecimento de ensino. Em tal situação, torna-se dispensável a comprovação de que o acusado comercializava entorpecentes erigindo diretamente os alunos da escola como público alvo, uma vez cuidar-se de causa de aumento de natureza objetiva." (Ap. nº 0039706-12.2014.8.26.0224; Relator(a): Grassi Neto; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 19/05/2016; Data de registro: 19/05/2016) (grifo nosso)

Apenas para consignar, o esforço das Defesas em desqualificar os depoimentos das testemunhas policiais não é suficiente para retirar a força probante deles.

Ressalte-se que os depoimentos das testemunhas policiais militares, colhidos durante a instrução criminal, mostram-se coerentes e harmônicos quanto às circunstâncias em que se deu a abordagem dos réus e a localização dos entorpecentes no interior da bolsa dispensada ao solo pelo acusado Matheus, e encontram-se em consonância com suas declarações prestadas perante a Autoridade Policial.

Destaque-se que as testemunhas policiais ressaltaram ter visualizado os dois acusados juntos, em local já conhecido como ponto de tráfico de drogas, e afirmaram ter visto o corréu Matheus portando uma bolsa de cor preta.

Afirmaram que, ao notarem a presença da equipe policial, o acusado Matheus largou a bolsa que estava segurando, deixando-a no chão, e ambos os réus tentaram sair do local, mas foram abordados.

Consignaram, ainda, que na bolsa dispensada pelo acusado Matheus foram encontradas diversas porções de entorpecentes variados e, com os corréus foram encontradas quantias em dinheiro.

Ao contrário do alegado pela Defesa de Matheus, não há, de acordo com a prova produzida, qualquer dúvida de que a bolsa contendo drogas efetivamente estava em posse do acusado Matheus, não havendo, também, dúvidas de que os entorpecentes pertenciam a ele.

De outro lado, nenhuma testemunha arrolada exclusivamente pela Defesa de Matheus foi trazida em Juízo para ser ouvida, a fim de esclarecer os fatos ou, ao menos, contrariar concretamente a versão apresentada pelas testemunhas policiais.

Assim, a negativa do acusado Matheus e a versão por ele apresentada de que teria se dirigido ao ponto de tráfico para vender sua bicicleta ao indivíduo que lá estaria realizando a venda de drogas, de que teria recebido deste o valor de R\$250,00 pela venda do bem, bem como de que o verdadeiro traficante, ao evadir-se do local já na posse de sua bicicleta, teria deixado cair no chão a bolsa que ele portava e que continha drogas, não se mostraram críveis e restaram absolutamente isoladas do contexto probatório, devendo-se considerar os demais elementos de convicção existentes e produzidos durante o processo.

Veja-se que nem mesmo o teor do interrogatório do corréu Kayky, cuja versão também se mostrou inverossímil, beneficia o acusado Matheus. Alegou Kayky que sequer teria presenciado o momento em que o acusado Matheus foi abordado e as drogas foram apreendidas.

Assim, na hipótese, seria mesmo um contrassenso pretender que a versão fornecida pelo acusado Matheus sobreponha-se aos depoimentos dos policiais militares encarregados de sua prisão, depoimentos estes que estão em harmonia com as demais circunstâncias que envolvem o delito.

Em outras palavras, impossível seria desmerecer os depoimentos dos policiais, pois são absolutamente aptos e suficientes para embasarem a inequívoca conclusão de que o réu Matheus é de fato traficante.

No presente caso os elementos de convicção são contundentes, seja em virtude da quantidade das drogas apreendidas, seja pela ação policial, tudo aliado à negativa isolada do réu.

Apenas para consignar, não há nada nos autos que pudesse justificar a conclusão de que o réu Matheus estaria sendo acusado injustamente da prática do delito de tráfico de drogas.

Dessa forma, pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do acusado Matheus, evidencia-se, pois, a realização do tráfico por ele.

Em arremate, a intenção mercantilista do réu Matheus deriva da variedade e da considerável quantidade de drogas e demais circunstâncias em que estas e também o dinheiro foram apreendidos.

De mais a mais, "para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da infração etc." (TJRJ - AC 1.327/92 - Rel. Adolphino A. Ribeiro - RDTJRJ 20/310).

Passo à dosagem da pena.

De outra banda, não há nos autos elementos suficientes para embasar a condenação do corréu Kayky quanto ao crime de tráfico de drogas.

Inferi-se da prova colhida em Juízo que o acusado não foi visto pelos policiais em

posse de nenhum entorpecente apreendido.

Depreende-se, ainda, da prova amealhada, que os policiais avistaram os dois acusados em local já conhecido pela ocorrência do tráfico de drogas, porém viram somente o acusado Matheus portando a bolsa onde constatou-se, após a abordagem, haver entorpecentes.

Da mesma forma, dessume-se dos depoimentos judiciais das testemunhas policiais que somente o acusado Matheus prestou declarações informais quando abordado e foi somente ele que apontou o corréu Kayky como sendo um indivíduo que com ele dividiria a ilícita tarefa de venda de drogas.

Em que pese, como já ressaltado, a versão do acusado Kayky não se mostrar crível, pois alegou que foi abordado em local diverso em que estaria o corréu Matheus, nada mais há nos autos a indicar que o acusado Kayky efetivamente estaria no local dos fatos praticando, em conjunto com o corréu Matheus, o crime de tráfico de drogas ou que estaria, de qualquer forma, participando deste delito.

Assim, em relação ao acusado Kayky, para se lançar uma condenação, é imprescindível a certeza ampla de ser ele coautor do crime ou ter ele concorrido para o crime que lhe foi atribuído. Se houver qualquer dúvida no espírito do julgador, a absolvição é medida que se impõe, porquanto a liberdade de uma pessoa não pode ser coarctada sem que a acusação seja comprovada por provas exatas e seguras.

Frise-se que sua inocência não é patente.

Todavia, diante desse quadro probatório e havendo sérias dúvidas no que pertine à participação no crime descrito na denúncia, a absolvição de Kayky é medida que se impõe, pois antes absolver provável culpado a condenar inocente.

Finalmente, quanto ao delito tipificado no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, não há prova suficiente produzida sob o crivo do contraditório que possa embasar um decreto condenatório.

Não restou demonstrado que os acusados efetivamente estavam associados entre si, organizando-se previamente para a prática do delito de tráfico de drogas, pois nem mesmo há demonstração suficiente da prática do delito de tráfico de drogas pelo acusado Kayky.

Não havendo prova suficiente, portanto, sobre o delito tipificado no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, devem ser os acusados absolvidos desta imputação, pois, como se sabe, a dúvida sempre deve ser resolvida em favor dos réus.

Diante do cotejo probatório trazido aos autos, de rigor a condenação do acusado Matheus pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos da fundamentação exposta.

Parcialmente procedente a ação penal, passo a dosar a pena do delito de tráfico de drogas quanto a Matheus.

Diante da natureza e variedade das drogas apreendidas, circunstâncias que demonstram a maior periculosidade do réu, pois não se trata de pequeno traficante, mais sim de grande disseminador do entorpecente, justifica-se o aumento da pena.

Assim, fixo sua pena-base em de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no valor mínimo legal.

Na segunda fase de fixação da pena, verifico que o delito foi cometido em ocasião de calamidade pública. Em que pese a vigência somente até 31 de dezembro de 2020 do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em âmbito federal, verifica-se que o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo, decorrente da pandemia do COVID-19, foi reconhecido por meio do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que ainda se encontra em vigência diante de sucessivas prorrogações. Portanto, em âmbito estadual, mantiveram-se vigentes as normas referentes ao reconhecimento do estado de calamidade pública. A agravante tem caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência. De qualquer forma essa circunstância não pode ser ignorada, pois o isolamento social e a quarentena, em razão da pandemia, facilitam a prática do crime. Impõe-se, portanto, o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Assim, aumento a pena em 1/6, ficando ela fixada em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e

pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor já estabelecido.

Não há circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não há causa de aumento a ser reconhecida e não é possível reconhecer-se a causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, diante da considerável quantidade de drogas apreendidas.

Com efeito, não caracteriza ofensa ao princípio do ne bis in idem a utilização da natureza da droga como circunstância judicial negativa para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria e o reconhecimento da grande quantidade de drogas, na terceira fase, para fins de modular ou afastar a redutora prevista na Lei de Drogas.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. MODULAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA ALTERNATIVA. PENA SUPERIOR A 1 (UM) ANO. UMA RESTRITIVA E OUTRA DE MULTA MAIS BENÉFICA. IMPROCEDÊNCIA. FACULDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária vinculada do julgador, será revista apenas nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, quando não observados os parâmetros estabelecidos na legislação de regência e o princípio da proporcionalidade. 3. Não configura bis in idem a aferição desfavorável da natureza da droga (cocaína), na primeira etapa da dosimetria, para majorar a pena-base e a utilização da quantidade (567 gramas) na escolha da fração do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (Precedentes do STJ e do STF). 4. Fixada a sanção corporal em patamar superior a 1 (um) ano, compete ao julgador a escolha do modo de aplicação da benesse legal prevista no art. 44, § 2º, segunda parte, do CP, substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos (Precedente). 5. Ordem não conhecida. (HC 386934 / SC HABEAS CORPUS 2017/0020104-9, Relator(a): Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 16/03/2017, PUBLIC 23/03/2017 - g.n.).

Ademais, a grande quantidade, a diversidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, além de responder o acusado por outro processo pelo mesmo delito, em que há condenação ainda não transitada em julgado (certidão de fls. 40), indicam que o réu faz do tráfico de drogas seu meio de vida, ou seja, dedica-se à atividade criminosa, não podendo ser considerado como pequeno traficante.

Veja-se, nesse sentido, o entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTUM PROPORCIONAL À NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. III - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para a fração do tráfico privilegiado, ante a

natureza bastante lesiva da substância ilícita (crack), em consonância com o atual entendimento do col. Pretório Excelso, bem como desta eg. Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 630.134/RS, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

Torno essa pena definitiva na ausência de outras modificadoras.

Considerando as peculiaridades do presente caso e as condições previstas no artigo 59 do Código Penal, cuidando-se de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, cujo aspecto altamente nocivo à sociedade em geral ninguém desconhece, por certo que não se afigura socialmente adequada e recomendável à situação a aplicação de penas alternativas ou outros benefícios que, por sinal, implicaria sensação de impunidade e incentivo à prática delituosa, frustrando-se a expectativa social, que exige e espera, em tais condições, efetiva e eficaz resposta à criminalidade cada vez mais crescente, motivos pelos quais fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena.

Não estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa por liberdade por restritiva de direitos. Também incabível o sursis.

Finalmente, não há se cogitar da aplicação imediata do disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos a respeito do seu comportamento no cárcere, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo Juízo das Execuções.

A lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o Código Penal e não o Código de Processo Penal. A progressão de regime vem, por sua vez, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada a progressão, imprescindível que sejam analisados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o do Juízo das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Nesse sentido:

"Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria bem demonstradas - Testemunho dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa - Ré confessa, ademais - Não incidência do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que não preenchidos os requisitos subjetivos - Precedentes - Pena de multa que se corrige - Mínimo erro material do r. juízo em detrimento da apelante - Regime fechado justificado - Impossibilidade de substituição da física por restritiva de direito - Detração - Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais - Recurso desprovido, com observação." (TJSP - Ap. Nº 0003591-97.2014.8.26.0577 - 4ª Câmara - Rel. Ivan Sartori - J. 28.04.2015 - grifei)

Deve-se ressaltar, ainda, que a detração neste momento processual causaria a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

1. CONDENAR o réu MATHEUS SILVA GALDINO PEREIRA, qualificado nos autos, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, bem como para ABSOLVÊ-LO da imputação que lhe foi feita de ter praticado o delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, o que faço com supedâneo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
2. ABSOLVER o réu KAYKY SOUZA SILVA ALVES, qualificado nos autos, das imputações que lhe foram feitas, quais sejam, a de ter praticado os delitos previstos no artigo 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, o que faço com supedâneo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Diante da absolvição do acusado KAYKY, expeça-se Alvará de Soltura Clausulado.

Nego ao réu MATHEUS o direito de apelar desta em liberdade, estando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, considerando-se os malefícios inerentes ao tráfico de drogas ao meio social.

Destaca-se, ainda, a quantidade, a natureza e a variedade de entorpecentes apreendidos com o acusado, o que, como também já ressaltado, demonstra que não se

trata de pequeno traficante, mais sim de um grande disseminador dos entorpecentes. Finalmente, não há qualquer alteração da situação fática ou jurídica que justifique a reconsideração da decisão que decretou a custódia cautelar no presente feito, mormente no momento em que foi proclamado culpado em primeiro grau de jurisdição. Portanto, verifico que ainda estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo de rigor manter a prisão preventiva, cumprindo-se, outrossim, o disposto no parágrafo único do artigo 316 do mesmo diploma legal. Recomende-se o réu MATHEUS na prisão em que se encontra.

Decreto o perdimento do valor de R\$253,80 apreendido nos autos, relacionado ao acusado MATHEUS, em favor da União, com fundamento no artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Defiro a restituição ao acusado KAYKY do aparelho celular e do valor com ele apreendido (R\$15,00 – fls. 6/7), diante de sua absolvição, providenciando-se, após o trânsito em julgado desta sentença com relação a este réu, o necessário para a devolução.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 29 de abril de 2022.

ALEXANDRE TORRES DE AGUIAR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA